

家工作人员。《最高人民法院关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解释》规定，国有公司、企业委派到国有控股、参股公司从事公务的人员，以国有公司、企业人员论。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第六条规定，国家出资企业中国家工作人员是指：经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。具体的任命机构和程序，不影响国家工作人员的认定。经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应当认定为国家工作人员。国家出资企业中的国家工作人员，在国家出资企业中持有个人股份或者同时接受非国有股东委托的，不影响其国家工作人员身份的认定。《最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》规定，在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员，除受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派从事公务的外，不属于国家工作人员。对其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，以职务侵占罪定罪处罚。根据上述规定，本案被告人王某某虽在国有控股上市公司的子公司中从事部门管理工作，但并非受国有公司、企业、事业单位委派从事公务，其任职也非经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准，不属于国家工作人员，故不具备公职职务犯罪的主体资格。

（二）被告人王某某不具有非法经营同类营业罪及背信损害上市公司利益罪的主体资格

非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的行为。非法经营同类营业罪的犯罪主体为特殊主体，即国有公司、

企业的董事、经理，根据《中华人民共和国公司法》的规定，董事包括董事会组成人员中的董事长、副董事长、执行董事及一般董事，经理则由董事会聘任、对董事会负责，负责公司的日常生产经营管理工作等。实践中，很多公司将其内部中层管理人员、内设机构负责人等也称为经理，但部门经理并非负责整个公司的经营管理，其经营管理权仅限于本部门，作为非法经营同类经营罪系属法定犯，在刑法没有明确规定的情况下，本着刑法谦抑性原则，非法经营同类营业罪的主体不应扩大至国有公司、企业的部门经理等中层管理人员。

背信损害上市公司利益罪，是指上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，致使上市公司利益遭受重大损失的行为。该罪的犯罪主体亦为特殊主体，即上市公司的董事、监事、高级管理人员，本案被告人王某某所任职的公司虽然系国有上市公司的全资子公司，但其具有独立主体资格，并非上市公司本身，故被告人王某某首先不具有上市公司人员的身份；此外，其系上市公司下属子公司的部门副经理，不属于董事、经理，根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第一项的规定，高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。因此，在公司章程未明确规定部门负责人为高级管理人员的情况下，公司内设部门经理等中层管理人员亦不属于公司高级管理人员。

二、从利益损失对象来看，本案遭受利益损失的对象并非被告人王某某所任职公司而是某食品公司

本案审理过程中，还有一个难点问题，即本案被害单位的认定问题。某食品公司与广告公司在广告业务上有一定的合作，某食品公司由陈某某作为代表，广告公司由王某某作为代表，双方对接广告业务，若按正常商业合作来看，涉案广告业务可由广告公司以正常的市场价格获取，却由王某某等人私下成立的公司获取，通过中间交易环节再交由广告公司具体实施业务，被告人王某某再从中获取差价及返点，则此差价及返点属于广告公司本应该获取的利益，则被害单位应认定广告公司。但在案的证据证实，本案广告公司一方相关人员证实

该公司与某食品公司的合作并非常态化，某食品公司给其的广告订单也不多，某食品公司并非必然地会把涉案广告业务交给其公司，且即便本案的交易，通过王某某的操作最终将某食品公司的广告业务交由该公司具体实施，该公司仍是有利可图的，故广告公司实际上在本案中并没有遭受可得利益的损失，且广告公司也多次表示其不是被害单位。综上，本案广告公司并非本案被害单位。

相反，本案，被告人陈某某作为某食品公司的工作人员，伙同被告人王某某成立某文化传媒公司，后该公司通过被告人陈某某的职务便利获取涉案4单广告代理合同业务，某文化传媒公司再将其中的3单广告代理业务通过某广告公司过单给广告公司，某食品公司涉案广告业务如果不需要经过中间交易环节，直接与终端商进行交易，就不存在层层差价、返点的问题，实际上被告人陈某某将某食品公司的涉案广告业务交给某文化传媒公司，合同价格已经包含希望获取的差价及返点金额，被告人陈某某等人获取的该差价及返点金额系某食品公司本不应该支出的钱款，系属某食品公司的财产，故本案遭受利益损失的对象为某食品公司。

三、从犯罪构成要件来看，本案二被告人的行为构成职务侵占罪的共同犯罪而非分别构成对非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪

对非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪系对向犯，对非国家工作人员行贿罪，是指为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以数额较大以上财物的行为，非国家工作人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人数额较大以上财物或者非法收受他人数额较大以上财物，为他人谋取利益。该两罪的行为特征为受贿人必须实施利用职务上的便利，索取行贿人财物或者非法收受行贿人财物为行贿人谋取利益的行为，即所侵犯的法益为公司、企业或者其他单位的正常管理活动和公平竞争的市场经济秩序。职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利将本单位数额较大的财物占为己有的行为。从职务侵占罪的构成要件来看，该罪侵犯的客体是单位的财产权；客观方面表现为利用职务上的便利，将本单位数额较大的财物非法占为己有的行为；犯罪主体为

特殊主体，即公司、企业或者其他单位的人员；主观方面由故意构成，且具有将本单位财物非法占为己有的目的。

本案中，被告人陈某某将涉案广告代理业务交由其与被告人王某某合作成立但其本人未实际出资的某文化传媒公司代理，后某文化传媒公司通过将广告业务通过中间交易环节过单最终交由被告人王某某任职公司实施赚取利润及返点279.7万元，虽然在形式上是某文化传媒公司通过交易所获取的利润，但从其本质来看，被告人陈某某作为某食品公司的工作人员，伙同被告人王某某成立某文化传媒公司，后该公司通过被告人陈某某的职务便利获取涉案4单广告代理合同业务，某文化传媒公司再将其中的3单广告代理业务通过某广告公司过单给广告公司，并从广告公司处赚取差价和返点，被告人陈某某、王某某明知广告业内广告代理公司存在赚取返点、差价的情况，仍通过双方合作设立的公司获取被告人陈某某所任职公司的广告代理业务，并通过虚设中间交易环节以赚取可能的差价及返点，现有证据不能证实某食品公司确有设立中间交易环节必要性的情况下，某食品公司与某文化传媒公司签订的广告代理合同价款实际上包含了某文化传媒公司将业务过单给其他公司可能获取的差价及返点，被告人陈某某伙同被告人王某某利用被告人陈某某的职务便利，将包含可能获取的差价及返点金额的合同价格报给某食品公司并最终得到确认，后获取相应的差价款及返点金额，某文化传媒公司所获利益即是侵害了某食品公司的利益，某文化传媒公司通过赚取返点、合同价差所获取的非法利益均即为某食品公司的损失，被告人陈某某作为某食品公司的员工，被告人王某某虽非某食品公司员工，但二人合谋利用被告人陈某某职务上的便利侵占某食品公司的财物，被告人陈某某获取利益是通过合作成立公司的方式侵占差价及返点，而非获取被告人王某某的行贿款，被告人王某某交给被告人陈某某的款项系属侵占款项的分赃款，本案侵犯的法益最主要的是公司的财产权益而非公平的市场竞争秩序，故二被告人的行为符合职务侵占罪的构成要件，共同构成职务侵占罪。

司法实践中，行为人实施职务侵占的手段更多的是利用职务便利进行窃取、骗取、侵吞的直接结果，中间没有任何中间环节，如将为自己购买家具的价款

开具办公用品发票直接从单位报销或者将代收的货款直接侵占等，但也不乏与本案类似情节的案件。行为人出于非法占有之目的，借交易之名故意抬高价格“收买”或者降低价格“卖出”，或者本无设立中间环节的必要时而设立中间环节并不经手居中获取“利益”，或者设立近乎空壳公司的中间环节经手但交易成本极低，谋取远远高于出售价或者远远低于收购价所获取的暴利，且该暴利为中间环节的设立者所控制占有，此种情形即为典型的职务侵占犯罪，如符合国家工作人员主体身份，则构成贪污罪。

编写人：福建省晋江市人民法院 廖文斌

69

## 公立医院合同制收费员将收取的 医药费用占为己有的构成职务侵占罪

——张某职务侵占案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

福建省宁德市中级人民法院(2022)闽09刑终195号刑事判决书

#### 2. 案由：职务侵占罪

### 【基本案情】

张某于2012年3月进入某疗养院任计算机系统管理员，其于2013年2月至3月离职，复职后担任收费员一职，为合同制员工，负责门诊、住院病人预交金的收、退及日结上缴工作，2019年5月开始成为某劳务派遣公司福鼎分公司派遣工、2021年5月开始成为某1劳务派遣公司派遣工，仍与吴某某、邓某某一同担任某疗养院的窗口收费员，收费员的职责为依托该院天资收费系统，

将个体病人支付的预交款统一存入该医院专户，在病人诊疗结束后进行费用结算时，可由任一收费员登录系统扣除病人诊疗应收款项后，为病人办理退还多缴预收款。因该医院系统不支持退款原路径返还，仍由收费员以现金形式为病人办理退款。自2020年9月5日起，张某利用其之前担任计算机系统管理员掌握的该院天资收费系统管理员权限先后虚开三个门诊号，分别盗用收费员吴某某及出纳刘某某此前担任收费员时的账号，往其中一个门诊号进行虚假预交金充值。此后，张某又盗用已退休收费员叶某某的账号，往三个门诊号和住院病人陈某某、马某某两个住院号进行虚假预交金充值，再用其本人的账号对上述两个住院号及三个门诊号办理退费，虚增所生成的日结报表中预交金退费金额，以此为手段少向出纳上缴其收取的预交金，将部分钱款套出予以侵吞。截至2022年2月13日案发，张某共计侵吞结存住院费、门诊费人民币824925.20元，用于个人日常生活开支及偿还债务。2022年2月13日，某疗养院财务人员发现门诊收费异常，该院于次日上午调整张某工作岗位，张某即向单位主动说明相关情况。当晚，某疗养院以谈话为由电话通知张某到单位，张某随即被福鼎市公安机关传唤，到案后如实供述罪行。

### 【案件焦点】

张某作为受聘于公立医院的合同制收费员，负责处理医院门诊、住院病人各类款项的收取、核算、结算，其将所收取的医药费用非法占为己有的行为如何定性。

### 【法院裁判要旨】

福建省福鼎市人民法院经审理认为：某疗养院作为民政局设立的事业单位，根据《中华人民共和国刑法》第九十一条的规定，其所有及管理的财产均属公共财产，包括被告人张某所收取的病人预缴的医疗费用。被告人张某虽系聘用人员，但其所收取的病人预缴的医疗费用在进入疗养院财务管理系统后已属于公共财产，具有国有公款的性质。被告人张某在履行收费员职责的过程中，利用疗养院财务管理上的漏洞，采取虚设病人门诊号、盗用其他收费员账号、虚

假充值、虚增退费的手段骗取已处于疗养院管理中的财产，侵犯的法益是公共财产的所有权，其行为特征符合贪污罪的构成要件，应以贪污罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名有误，应予更正。被告人张某具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚，并从宽处理。被告人张某积极退出部分赃款，予以酌情从轻处罚。据此，以贪污罪判处被告人张某有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10万元。

一审宣判后，张某提出上诉。

福建省宁德市中级人民法院经审理认为：上诉人张某在担任某疗养院收费员期间，利用职务上的便利，非法侵占本单位财物价值达人民币824925.20元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。原判定性不当，予以纠正。上诉人张某主动投案，到案后如实供述罪行，具有自首情节，予以从轻处罚。上诉人张某到案后积极退出部分赃款，予以酌情从轻处罚。据此，判决如下：

一、维持福建省福鼎市人民法院(2022)闽0982刑初163号刑事判决第二项对责令退赔之判决；

二、撤销福建省福鼎市人民法院(2022)闽0982刑初163号刑事判决第一项对上诉人张某定罪量刑之判决；

三、上诉人张某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10万元。

### 【法官后语】

对于医院收费员将收取的医药费用占为己有行为性质的认定，在司法实践中一直存在较大争议。从本案情况来看，张某作为一名医院聘请的合同制收费员，其所做的工作是负责处理门诊、住院病人各类款项的收取、核算、结算，其所从事的工作实质是服务性的劳务工作，不属于在国有事业单位中从事公务的人员，不具备贪污罪的主体资格，其行为应定性为职务侵占罪。理由如下。

1. 《中华人民共和国刑法》第三百八十二条规定，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国

有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。根据该条的规定，贪污罪的主体包括两类：一类是国家工作人员，侵犯的对象是公共财物；另一类是受委托人员，侵犯的对象是国有财物。

2. 《中华人民共和国刑法》第九十三条规定：“本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。”《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）第一条关于贪污贿赂犯罪和渎职犯罪的主体的规定，对国家机关工作人员以及“国家机关中从事公务的人员”以外的国家工作人员的范围作出了明确规定，同时又对何谓“从事公务”作出了明确阐释，并成为司法实践中认定国有事业单位中“从事公务的人员”的参考标准。《纪要》规定：“从事公务，是指代表国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等履行组织、领导、监督、管理等职责。公务主要表现为与职权相联系的公务事务以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事公务。那些不具备职权内容的劳务活动、技术服务工作，如售货员、售票员等所从事的工作，一般不认为是公务。”对于非行使组织、领导、监督、管理职权的劳务活动、技术服务工作，不论行为人是否具有干部身份，只要其所从事的工作不具有职权内容，一般不认为是从事公务。同样，行为人从事与公务行为无关的私人行为构成犯罪时，也不应认定为从事公务时实施的犯罪。

3. 贪污罪主体还有一类为：虽非国家工作人员，但受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利非法侵占本单位财物的。受委托管理、经营国有财产的人员不是国家工作人员，也不能以国家工作人员论，因此，只能成为贪污犯罪的主体，不能成为受贿、挪用公款等其他国家工作人员职务犯罪的主体。在形式上，无论是在



受托前还是在受托后，受托人与委托单位之间都不存在行政上的隶属关系。对于国有单位中非从事公务的工作人员，即使是合同工，一旦在国有单位内部承担管理、经营国有财产的职责，则应当直接认定为国有单位中从事公务的人员，而不是受委托管理、经营国有财产的人员；如其被国有单位聘用后指派到非国有单位管理、经营国有财产，则属于受委派从事公务的人员，也不是受委托管理、经营国有财产的人员。实质上，受托人行使了管理、经营国有资产的职责。这里的“管理国有资产”，是一种具有公共事务性质的活动，不仅意味着对国有资产进行保管，通常还意味着受托人对国有财产具有一定的处分权。所谓管理，是指具有监守或者保管公共财物的职权。经营者在经营期间通常同时行使管理职权，对公共财物具有处置权。所谓经营，是指将公共财物投放市场并作为资本使其增值的商业活动，或者利用公共财物从事营利性活动。虽然管理、经营国有财产也是从事公务的具体表现，由于受委托管理、经营国有财产的人员，并不属于受托单位的工作人员，因此，不属于国家工作人员。鉴于此，“受委托管理、经营国有财产”，应理解为承包、租赁、临时聘用等管理、经营国有财产。

4. 本案中，某疗养院虽然系国有事业单位，张某作为一名劳务公司派遣到该院的合同制员工，本身并不具有国家干部身份，从其工作内容看仅限于服务性的收取、核算、结算各类病人门诊、住院费用的劳务工作，其虽然对收取的医药费用有一定的保管或管理职责，但这仅仅是其作为收费员一种当然义务，是通过其劳务活动对医药费进行收取、核算和暂时管理，本质上是其劳务活动的组成部分，其对该院的财物实质上没有管理支配权，其所从事的工作属于不具备职权性、管理性、代表性的劳务性工作，不具有代表疗养院进行组织、领导、监督和管理的职能，不应认定为国有事业单位中从事公务人员，也不属于受委托管理、经营国有财产人员，不具备贪污罪的主体身份，其利用职务上的便利，非法占有单位财物，应构成职务侵占罪。

编写人：福建省宁德市中级人民法院 史玲芝

## (五)敲诈勒索罪

70

### 敲诈勒索罪与强迫交易罪的区分认定技巧

#### ——耿某敲诈勒索案

#### 【案件基本信息】

##### 1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终243号刑事判决书

##### 2. 案由：敲诈勒索罪

#### 【基本案情】

2019年至2022年，被告人耿某在网络上发布网上批量开通证券账户的广告。在证券公司从业人员联系耿某委托批量开户后，耿某以显著超过约定数量、不符合约定种类或要求的开户清单要求结算，并通过反复向对方所在证券公司及证券监督管理部门投诉、举报违规开户向对方施加压力，利用证券公司从业人员害怕受处罚、被辞退等的心理，迫使对方处理解决投诉的过程中按耿某意愿支付钱款后才同意撤诉。耿某以此手段分别敲诈勒索被害人黄某1万元、陈某1.6万元、赵某12万元、王某2.3万元、傅某3.6万元，共20.5万元。耿某又企图以同样手段敲诈勒索被害人姜某7万元，后姜某未支付钱款，向公安机关报案。

### 【案件焦点】

1. 以举报违规为由索取财物，是否构成敲诈勒索；2. 被告人的犯罪行为构成是敲诈勒索罪还是强迫交易罪。

### 【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院经审理认为：关于耿某及其辩护人提出耿某合法举报他人违规是正常维权行为，如构成犯罪应当构成强迫交易罪。经查，耿某无真实的交易意思，开户交易是其索财的工具，耿某主观上具有非法占有为目的；耿某利用他人弱点以举报、投诉、撤诉作为要挟，给被害人造成处罚、失业的心理恐慌，迫使被害人无奈交付钱款，客观上实施敲诈勒索的行为，该辩解与辩护意见不成立，法院不予采纳。耿某以非法占有为目的，多次采用要挟手段，索取他人财物，其行为构成敲诈勒索罪，且数额巨大。此外，耿某企图敲诈勒索姜某，已着手实行而因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂。

广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条第二款、第八条之规定，作出如下判决：

一、被告人耿某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；

二、责令被告人耿某退赔被害人黄某的经济损失人民币1万元，退赔被害人陈某的经济损失人民币1.6万元，退赔被害人赵某的经济损失人民币12万元，退赔被害人王某的经济损失人民币2.3万元，退赔被害人傅某的经济损失人民币3.6万元；

三、被告人耿某的作案工具蓝绿色手机一部、黑色手机一部，依法予以没收，上缴国库。

一审宣判后，耿某提出上诉，并在二审期间其亲属代其通过一审法院退赔各被害人的全部经济损失共计20.5万元。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。二审期间上诉人耿某通过亲属退赔了被害人的全部经济损失，具有一定悔罪表现，可在原判基础上酌情对其进一步从轻处罚。原判审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二项，《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条第二款、第八条之规定，作出如下判决：

一、维持广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院(2023)桂0205刑初198号刑事判决中的第二项、第三项，即责令被告人耿某退赔被害人黄某的经济损失人民币1万元，退赔被害人陈某的经济损失人民币1.6万元，退赔被害人赵某的经济损失人民币12万元，退赔被害人王某的经济损失人民币2.3万元，退赔被害人傅某的经济损失人民币3.6万元；被告人耿某的作案工具蓝绿色手机一部、黑色手机一部，依法予以没收，上缴国库；

二、撤销广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院(2023)桂0205刑初198号刑事判决中的第一项，即被告人耿某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元；

三、上诉人耿某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元。

### 【法官后语】

本案的争议焦点在于耿某的行为如何定性，耿某的行为属于解决民事争议的维权行为，还是构成敲诈勒索罪，或是构成强迫交易罪。

#### 一、耿某的行为不属于解决民事争议的维权行为

首先，双方纠纷不属于普通民事争议。虽然具有民事法律关系的外观，但耿某主张的权利是违规开户所得收益，违规开户违反证券监管部门的管理规定，双方的交易与收益都不具备正当性。且被害人陷入违规的错误中，与耿某有直接因果关系。其次，耿某主张权利超出正当合理限度。要求结算的开户清单，

